



訴願決定書

案 號： 1143070734

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 08 月 27 日

發文字號： 新北府訴決字第 1141214066 號

相關法條： 行政程序法 第 103、114 條

訴願法 第 14、77、79 條

行政罰法 第 42 條

建築法 第 2、73、91 條

新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準 第 3 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1143070734 號

訴願人 施○迅即芯○海養生館

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 114 年 4 月 25 日新北工使字第 1140751419 號函併附同文號行政處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分關於新臺幣 12 萬元罰鍰部分，訴願駁回。

原處分關於限期改善部分，訴願不受理。

事 實

緣訴願人為位於本市○○區○○路 1 段 65 號 1 樓、2 樓建築物〔領有民國（下同）77 土使字第 1742 號使用執照，樓層數為「地上 5 層、地下 1 層」，土地使用分區為「住宅區」，1 樓原核准用途為「店舖（G 類 3 組）、住宅（H 類 2 組）」，下稱系爭建築物〕之使用人，前經本府公共安全聯合稽查小組於 112 年 12 月 22 日實施聯合勘查，查得現場設有按摩床 8 床，經目的事業主管機關本府經濟發展局認屬經營「按摩業」，並依建築物使用類組及變更使用辦法對於建築物之使用類別、組別及其定義，係供作「按摩場所（B 類 1 組）」使用，原處分機關認系爭建築物有未依原核定之使用類組，擅自變更使用類組使用之情事，違反建築法第 73 條第 2 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 1 款及新北市政府違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定，以 113 年 1 月 23 日新北工使字第 1130159064 號函併附同文號行政處分書裁處訴願人新臺幣（下同）6 萬元罰鍰，並限期於 113 年 2 月 10 日前改善或補辦手續。

嗣本府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，現場查得 1 樓設有按摩床 8 床，並設有拉廉加以區隔，係將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所，涉有違反建築法規定等情，遂移由原處分機關處理。經原處分機關函請目的事業主管機關本府經濟發展局認定屬經營「按摩業」，原處分機關審認系爭建築物仍有上開違規情事，已違反建築法第 73 條第 2 項規定，遂依同法第 91 條第 1 項第 1 款及新北市政府違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定，以 114 年 4 月 25 日新北工使字第 1140751419 號函併附同文號行政處分書（下稱系爭處分書），裁處訴願人 12 萬元罰鍰（第 2 次），並限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續。訴願人不服，於 114 年 5 月 23 日提起本件訴願，並據原

處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：原處分機關在作成處分前，未依行政程序法及行政罰法之規定，給予訴願人陳述意見之機會，與其他從事類似業態之業者有差別待遇，程序上顯有違失，又查按摩業之主管機關為衛生福利部，惟經發局並未於臨檢當日派員到場，僅憑土城分局臨檢紀錄，即認定訴願人經營按摩業，顯非客觀且欠缺查證。然原處分機關竟僅依土城分局之臨檢紀錄及經發局 114 年 3 月 24 日新北經商字第 1140551698 號函，即認定系爭建築物作為「按摩場所」使用，並據以作成裁處，顯屬事實認定不明及法律適用不當，另訴願人業已辦理歇業登記，不再經營，請撤銷原處分，以維訴願人權益等語。
- 二、答辯意旨略謂：訴願人為系爭建築物之使用人，嗣經本府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，現場查得 1 樓設有按摩床 8 床，並設有拉廉加以區隔，係將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所，經目的事業主管機關本府經濟發展局認定屬經營「按摩業」，依建築物使用類組及變更使用辦法對於建築物之使用類別、組別及其定義，係供作「按摩場所（B 類 1 組）」使用，原處分機關認系爭建築物有未依原核定之使用類組，擅自變更使用類組使用之情事，違反建築法第 73 條第 2 項規定，原處分機關依建築法第 91 條第 1 項第 1 款據以裁處，並無違誤等語。

理 由

- 一、關於不服原處分裁處 12 萬元罰鍰部分：

- （一）按建築法第 2 條規定：「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」，本府 104 年 10 月 5 日新北府工建字第 1041856028 號公告：「主旨：本府關於建築法除違章建築處理事項外，所定主管機關權限劃分予本府工務局執行，並廢止本府 100 年 1 月 19 日北府工建字第 1000054371 號關於權限劃分之公告，均溯自 104 年 7 月 24 日生效」準此，本案原處分機關為有權限處分機關。
- （二）次按建築法第 73 條第 2 項：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第 9 條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照…。」、第 91 條第 1 項第 1 款：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：一、違反第 73 條第 2 項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。」及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 9 之規定。」附表 1 規定（摘錄如下）：
- （三）再按行政程序法第 103 條第 5 款規定：「有下列各款情形之一者，行政機關得不給予陳述意見之機會：五、行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者。」、行政罰法第 42 條第 6 款規定：「行政機關於裁處前，應給予受處罰者陳述意見之機會。但有下列情形之一者，不在此限：六、裁處所根據之事實，客觀上明白足以確認。」及最高行政法院 111 年度上字第 363 號行政判決要旨：「行政處分作成前，未依行政程序法規定記明其理由，或未給予當事人陳述意見的機會而有程序瑕疵，依行政程序法第 114 條第 1 項第 2

款、第 3 款、第 2 項前段規定，若在訴願程序終結前，已由原處分機關將理由補充予當事人知悉，當事人也依該等理由，有向原處分機關陳明其意見的機會，供原處分機關參酌而重新審查原處分合法、妥當性，以資決定是否撤銷或變更原處分者，就可認原處分的程序瑕疵已依上開規定而補正。」。

(四) 卷查系爭建築物領有 77 土使字第 1742 號使用執照，樓層數為「地上 5 層、地下 1 層」，土地使用分區為「住宅區」，1 樓原核准用途為「店舖（G 類 3 組）、住宅（H 類 2 組）」，前經本府公共安全聯合稽查小組於 112 年 12 月 22 日實施聯合勘查，查得現場設有按摩床 8 床，經目的事業主管機關本府經濟發展局認屬經營「按摩業」，並依建築物使用類組及變更使用辦法對於建築物之使用類別、組別及其定義，係供作「按摩場所（B 類 1 組）」使用，原處分機關認系爭建築物有未依原核定之使用類組，擅自變更使用類組使用之情事，違反建築法第 73 條第 2 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 1 款及新北市政府違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定，以 113 年 1 月 23 日新北工使字第 1130159064 號函併附同文號行政處分書裁處訴願人 6 萬元罰鍰，並限期於 113 年 2 月 10 日前改善或補辦手續。嗣本府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，現場查得 1 樓設有按摩床 8 床，並設有拉廉加以區隔，係將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所，涉有違反建築法規定等情，遂移由原處分機關處理。嗣經原處分機關函請目的事業主管機關本府經濟發展局，經該局以 114 年 3 月 24 日新北經商字第 1140551698 號函復，認應可歸屬經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」之經營「JF01020 按摩業」行業項目，原處分機關認系爭建築物有未依原核定之使用類組，擅自變更使用類組使用之違規事實，此有系爭建築物使用執照存根、本府警察局土城分局 114 年 3 月 13 日臨檢紀錄表、現場勘查照片數幀以及本府經濟發展局上開號函等附卷可稽。是原處分機關認訴願人違反建築法第 73 條第 2 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定，以系爭處分書裁處訴願人 12 萬元罰鍰（第 2 次），洵屬有據。

(五) 至訴願人主張原處分機關在作成處分前，未依行政程序法及行政罰法之規定，給予訴願人陳述意見之機會，與其他從事類似業態之業者有差別待遇，程序上顯有違失，又查按摩業之主管機關為衛生福利部，惟經發局並未於臨檢當日派員到場，僅憑土城分局臨檢紀錄，即認定訴願人經營按摩業，顯非客觀且欠缺查證。另訴願人業已辦理歇業登記，不再經營等語。惟按前揭法務部 103 年 10 月 27 日法律字第 10303512490 號函釋意旨，行政機關倘依其他所查事實及證據，已足證明違反法令之事實存在，仍得據以裁處行政罰。又查內政部 100 年 12 月 9 日內授營建管字第 1000810874 號函釋略以：「二、本部 100 年 9 月 1 日台內營字第 1000806985 號令修正發布並自同年 10 月 1 日施行之建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第 2 條第 1 項附表 1 及第 2 項附表 2 規定，B-1 使用組別定義為『供娛樂消費，且處封閉或半封閉之場所』，其使用項目舉例包括「…按摩場所（將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所）…」；另 G-3 使用組別定義為『供一般門診、零售、日常服務之場所』，其使用項目舉例包括『…、按摩場所（未將場所加以區隔且非包廂式為人按摩之場所）…」」。是關…按摩等類似場所置有內部裝修材料

、設施設備或其他物品，將該場所加以區隔為封閉（包廂式）或半封閉空間，致影響防火避難設施者，應依本辦法上開條文認定為 B-1 使用組別。…」」。因此，系爭建築物內係以布拉簾作為區隔，然此會遮蔽視線，一旦發生火災，現場民眾或工作人員較難立即察覺布拉簾內外之情形，易生未能及時避難之憾事，且火災發生，現場已因煙霧瀰漫或因停電，導致視線不佳，如尚有拉簾區隔場所，更易使民眾或工作人員錯失逃生先機，尤其系爭建築物之拉簾材質為布類，更加助長火勢，影響逃生避難（臺北高等行政法院 109 年度訴字第 859 號判決參照）。依卷附本府警察局土城分局 114 年 3 月 13 日臨檢紀錄表及現場勘查照片數幀，並經原處分機關調閱系爭建築物使用執照存根，函詢本府經濟發展局釋復後，本件訴願人明知系爭執照之原核准使用內容均供住宅及店舖使用，本應注意有變更使用類組時，應先申請變更使用執照，不得未經核准擅自變更使用，卻擅自變更使用類組使用，堪認其有違反建築法第 73 條第 2 項規定之情事甚明，本件客觀上已可確認原處分所根據之事實，依行政程序法第 103 條第 5 款、行政罰法第 42 條第 6 款規定，原處分機關得不給予陳述意見之機會。訴願人主張，尚難採憑。是原處分關於裁處 12 萬元罰鍰部分，於法並無違誤，應予維持。

二、關於不服原處分限期改善部分：

- （一）按訴願法第 77 條第 8 款規定，對於非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願者，應為不受理之決定。次按司法院釋字第 546 號解釋意旨略以：「…為訴願決定時，已屬無法補救者，其訴願為無實益，應不受理…旨在闡釋提起行政爭訟，須其爭訟有權利保護必要，即具有爭訟之利益為前提，倘對於當事人被侵害之權利或法律上利益，縱經審議或審判之結果，亦無從補救，或無法回復其法律上之地位或其他利益者，即無進行爭訟而為實質審查之實益…。」，是提起訴願亦須其訴願有權利保護必要，即具有訴願之實益為前提，合先敘明。
- （二）查訴願人於訴願書中表示已辦理歇業登記，並附有本府經濟發展局 114 年 5 月 22 日新北經登字第 1148155484 號函在卷可查，則訴願人就原處分關於限期改善部分之撤銷與否，已無可回復之法律上利益，而無撤銷實益，自屬欠缺權利保護之必要，非屬訴願救濟範圍事項，依訴願法第 77 條第 8 款規定，應為不受理之決定。

三、綜上論結，本件訴願為部分程序不合，部分無理由，依訴願法第 77 條第 8 款及第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員	蔡庭榕
委員	陳明燦
委員	陳立夫
委員	張文郁
委員	蔡進良
委員	黃源銘
委員	劉宗德
委員	景玉鳳
委員	王藹芸
委員	李永裕

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 8 月 27 日

相關圖表：新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第3點第1項之附表1
（摘錄）.PDF